

1501796-66.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas."

(TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a):

Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501796-66.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2316304/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21505253 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3311/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2316304 - 02º D.P. PIRACICABA,

3311/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAS FELIPE DA SILVA SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) JONATHAS FELIPE DA SILVA SANTOS, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Mayara de Souza Silva e Maycon Morato de Lima.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s)

acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Mayara e Maycon) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

JONATHAS FELIPE DA SILVA SANTOS foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 21 de novembro de 2021, por volta de 03h35m, na via pública, na avenida Professor Alberto Volet Sachs, altura do numeral 1.403, bairro Nova América, nesta cidade e comarca, qualificado a fls. 06, trazia consigo duas porções de cocaína e mantinha em depósito 58 porções de cocaína e 28 porções de maconha destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

Autoria e materialidade foram devidamente comprovadas.

Segundo se apurou, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local, quando avistaram o denunciado em local conhecido como “ponto de venda de drogas”, o qual estava parado na via pública. Feita abordagem de praxe, na sua posse foram encontradas 02 porções de cocaína e a quantia de R\$29,00 (vinte e nove reais) em notas trocadas.

Instado, o denunciado indicou onde mantinha o restante do entorpecente, ou seja, no terreno baldio, próximo ao local, dentro de uma sacola plástica foram localizadas 58 porções cocaína e 28 porções de “maconha”, as quais ele admitiu que se destinavam à mercancia ilícita.

Diante das circunstâncias apuradas, apreensão de porções individualizadas para venda e confissão informal do denunciado, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Com efeito, a testemunha Mayara de Souza Silva, policial militar, disse “a data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando se depararam com um homem que se encontrava parado na via pública, despertando suspeitas. Que o comportamento do suspeito era indicativo do tráfico de drogas. Que, realizada a abordagem, com o ora indiciado foram localizados 2 'pinos' contendo aparentemente COCAÍNA, uma faca e, ainda, a quantia de R\$ 29,00. Que, a partir de indicações do próprio averiguado, a depoente e seu parceiro lograram localizar, em um terreno baldio localizado do outro lado da via, uma sacola plástica dentro da qual estavam outros 58 microtubos contendo substância semelhante à COCAÍNA, idênticos àqueles encontrados em poder do suspeito, e também 28 porções aparentando serem de MACONHA. Que, indagado, o suspeito confessou a autoria delitiva. Que, tendo em vista os fatos acima, tudo denotando a prática do tráfico de drogas, conduziram o implicado a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário utilizar algemas.” (fls. 03).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. O horário e local chamaram a atenção. O réu estava em pé no ponto de ônibus e naquele horário não circula mais coletivos. Ele indicou o local que estava o restante da droga. O dinheiro era proveniente do tráfico. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, o policial Maycon Morato de Lima disse “na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando se depararam com um sujeito que, a julgar pelo seu comportamento, estava realizando o tráfico de entorpecentes. Que o indivíduo estava parado na via pública, em pé, aparentemente pronto para servir

drogas a eventuais clientes, sobretudo condutores de automóveis. Que, realizada a abordagem, com o ora indiciado foram localizados 2 'pinos' contendo aparentemente COCAÍNA, uma faca e, ainda, a quantia de R\$ 29,00. Que, indagado sobre a existência de mais drogas, o próprio averiguado indicou o local em que manteria outras porções de entorpecente homiziadas. Que, em um terreno baldio localizado do outro lado da via, foi localizada uma sacola plástica dentro da qual estavam outros 58 microtubos contendo substância semelhante à COCAÍNA, idênticos àqueles encontrados em poder do suspeito, e também 28 porções aparentando serem de MACONHA. Que, tendo em vista os fatos acima, tudo denotando a prática do tráfico de drogas, os ostensivos conduziram o implicado a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário utilizar algemas" (fls. 05).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Salvo engano no horário da abordagem não havia mais circulação de ônibus. Não conhecia o réu. Perto do réu não havia cobertor e papelão e ele não tinha aparência de morador de rua. Não apreendeu o réu quando ele era adolescente. Pediram apoio de outra viatura.

Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 06).

Em juízo disse que não estava trabalhando quando foi preso. Já respondeu a processo na Vara da Infância e Juventude e recebeu liberdade assistida. Alegou a inverossímil versão de que era morador de rua e havia sido ameaçado por um policial de que quando completasse 18 anos de idade seria preso por crime de tráfico. A droga apreendida não era sua. Iria dormir no ponto de ônibus porque estava muito cansado. O local não é ponto de venda de drogas. É usuário de crack e não consegue ficar sem. Não tinha dinheiro e faca na sua posse. Nada tem contra os policiais. Iria para o Capes fazer tratamento de dependência química antes de ser preso. Não teve registro de carteira de trabalho. Não se lembra quantas vezes respondeu pelo ato infracional assemelhado ao tráfico ilícito de drogas.

Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito imputado.

A narrativa dos policiais militares foi firme e uníssona em confirmar que avistaram o réu em lugar conhecido como "ponto de tráfico de drogas". Feita abordagem, em poder do réu foram localizadas duas porções de cocaína, além da quantia de R\$29,00. Outrossim, instado ele indicou que o restante da droga encontrava-se em um terreno baldio nas proximidades. Assim, em diligências no local indicado, foram localizadas 58 porções cocaína e 28 porções de "maconha". Informalmente, o réu confessou a prática ilícita.

A quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente não deixam dúvidas que a droga destinava-se à mercancia ilícita. Ademais, o réu foi surpreendido em local conhecido como "ponto de tráfico ilícito de drogas", o que torna evidente a mercancia ilícita.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos policiais, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carregado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso. Salienta-se que os policiais não tinham motivos para incriminá-lo injustamente. Destarte, diante do conjunto probatório, imperiosa a condenação do réu pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena poderá ser fixada no mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento.

Incabível, a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da

quantidade de drogas mantida no local, o que demonstra que o réu é contumaz e não se tratou de uma conduta isolada.

Ademais, o réu ostenta ação penal em andamento, o que demonstra que dedica-se a prática de crimes. Não bastasse, ele ostenta diversos atos infracionais, inclusive pela prática de ato análogo ao crimes em questão.

Vale salientar que, atos infracionais, embora não possam ser considerados maus antecedentes ou reincidência, são suficientes a demonstrar a dedicação do agente na prática de crime e, conseqüentemente, afastar eventuais benesse, principalmente o privilégio trazido na Lei de Drogas.

Neste sentido:

"PENAL.HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. INAPLICABILIDADE.ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DEDIREITO. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes da Quinta Turma.

4. Concluído pelas instâncias antecedentes que o paciente se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes, tendo em vista, além da quantidade e da variedade da droga apreendida (60,50g de maconha e 7,67g de cocaína), o fato de que ao tempo do delito em apreço, ele estava no curso de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

5. Estabelecida a pena definitiva em 5 anos de reclusão, revela-se correta a imposição inicial do regime fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada), tendo em vista a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, conforme o art. 33, § 2º, "a", e § 3º, c.c. o art. 59, ambos do CP, e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum da sanção aplicada (art. 44, I, do Código Penal).7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 364.837/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). GRIFO NOSSO.

No mesmo sentido, decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação - Tráfico de drogas - Recurso Ministerial e Defensivo - Ausência de impugnação no tocante ao mérito - Réu confesso em juízo - Confissão corroborada pelos demais elementos de prova Acusado preso em flagrante delito na posse de 54 gramas de cocaína e 84 gramas de maconha embaladas para o comércio ilícito - Condenação de rigor. Dosimetria - Redução da pena-base ao mínimo legal - Dolo normal à espécie delitiva - Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão - Afastamento da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 - A prática de atos infracionais em delitos da mesma natureza demonstram a dedicação à atividade criminosa e impedem a concessão da benesse - Inaplicabilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos - Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime - Mantido o regime fechado. Recurso

parcialmente provido para a defesa e provido para o Ministério Público. (Apelação nº 0003322-24.2013.8.06.0050, 11ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. Salles Abreu, Dj. 02.04.14).

Portanto, ausentes os requisitos para concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para a adequada prevenção e reprovação, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o réu iniciar o desconto da pena no regime inicial fechado.

A prisão preventiva do réu deverá ser mantida. Isso porque, os elementos acostados demonstram que ele é contumaz na prática delitativa. Portanto, não se tratou de uma conduta isolada e, colocado em liberdade, voltará a delinquir, até mesmo porque não possui trabalho lícito e faz do crime seu meio de sustento.

Não houve qualquer alteração fática.

A quantidade e natureza da droga é significativa, o que evidencia dedicação e contumácia. Ademais, o réu não comprovou trabalho lícito e as informações dão conta de que no local o tráfico ilícito ocorrida rotineiramente. Portanto, não se tratou de uma conduta isolada.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Jonathas Felipe da Silva Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 138-140), no dia 21 de novembro de 2021, por volta de 03h35, na via pública, na avenida Professor Alberto Volet Sachs, altura do numeral 1.403, bairro Nova América, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Jonathas trazia consigo duas porções de cocaína e mantinha em depósito 58 porções de cocaína e 28 porções de maconha destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Ainda de acordo com a inicial, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local, quando avistaram o réu parado em local conhecido como "ponto de venda de drogas", na via pública. Feita abordagem de praxe, na sua posse foram encontradas 02 porções de cocaína e a quantia de R\$ 29,00 (vinte e nove reais) em notas trocadas. Instado, o réu indicou onde mantinha o restante do entorpecente, ou seja, no terreno baldio, próximo ao local, dentro de uma sacola plástica foram localizadas 58 porções cocaína e 28 porções de "maconha", as quais o réu admitiu que se destinavam à mercancia ilícita.

Interrogado em solo policial, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 6).

Mayara de Souza Silva, policial militar, contou que: "na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando se depararam com um homem que se encontrava parado na via pública, despertando suspeitas. O comportamento do suspeito era indicativo do tráfico de drogas. Realizada a abordagem, com o ora indiciado foram localizados 2 'pinos' contendo aparentemente cocaína, uma faca e, ainda, a quantia de R\$ 29,00. A partir de indicações do próprio averiguado, a depoente e seu parceiro lograram localizar, em um terreno baldio localizado do outro lado da via, uma sacola plástica dentro da qual estavam outros 58 microtubos contendo substância semelhante à cocaína, idênticos àqueles encontrados em poder do suspeito, e também 28 porções aparentando serem de maconha. Indagado, o suspeito confessou a autoria delitativa. Tendo em vista os fatos acima, tudo denotando a prática do tráfico de drogas, conduziram o implicado a esta Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo necessário utilizar algemas" (fls. 4).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial Maycon Morato de Lima (fls. 5). Às fls. 41-42, juntadas certidões de objeto e pé e folha de antecedentes que indicam a primariedade do requerido. Registrados antecedentes infracionais datados de 2019 e 2020 (tráfico e furto).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12-14, laudo de constatação de fls. 16-20, fotografias de fls. 30-33 e laudo de exame definitivo de fls. 176-178.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, Mayara de Souza Silva, policial militar. Estavam em patrulhamento. O réu estava no ponto de ônibus em local conhecido pelo tráfico. O local e o horário levantaram suspeita. Era por volta de 3h ou 4h da manhã. Os ônibus na cidade não circulam nesse horário. Decidiram abordar. Jonathan estava em pé no ponto de ônibus e sozinho. Revistado, com ele havia 2 pinos de cocaína, R\$29,00 em dinheiro trocado e uma faca. Perguntado, Jonathan indicou o local onde o restante do entorpecente, cocaína e maconha, estava escondido. Ficava no outro lado da via, em uma área de mata. As drogas estavam em uma sacola próximo a uma árvore. Não conhecia o réu. Foi a primeira vez que o abordou.

b) Em seguida, ouvido Maycon Morato de Lima, policial militar. Estava em patrulhamento ostensivo. Avistou o réu, realizou a abordagem. O local é conhecido pelo tráfico. Com Jonathan localizaram 2 pinos de cocaína, 1 faca e R\$ 29,00. O acusado confessou a traficância e apontou a mata onde estava escondido o restante da droga. A mata fica do outro lado da avenida. Na mata, havia uma sacola com maconha e cocaína. Ao ser abordado, Jonathan estava sozinho e sentado. No horário da abordagem, salvo engano não há circulação de ônibus. Não conhecia o réu. Não identificou com Jonathan objetos que indicassem que ele estava em situação de rua ou que pretendia dormir no ponto de ônibus. Não conhecia o réu e não o apreendeu quando adolescente. Outra viatura participou da ocorrência, mas não sabe dizer se algum dos policiais conhecia Jonathan ou o tinha apreendido quando era adolescente.

c) Por fim, foi interrogado o réu Jonathas Felipe da Silva Santos. Indicou que estava em situação de rua antes de ser preso. Relatou que foi abordado em ocasião anterior, um policial lhe pediu indicação de um traficante chamado "Peixe", e disse que, se ele não tivesse a informação depois que deixasse de ser adolescente, seria preso. No dia dos fatos, o referido policial o abordou no ponto de ônibus, onde estava dormindo. Como ele não sabia indicar o traficante, ele foi preso. Outras viaturas chegaram, entraram na mata, pegaram droga e disseram que era dele. O policial não é o depoente. Estava em outra viatura. Não sabe o nome dele. Os policiais depoentes chegaram depois, em reforço à viatura que inicialmente o abordou e onde estava o policial que o ameaçou. A droga apresentada estava na viatura. A policial foi ao mato, trouxe uma meia com drogas e disse que era dele. Estava se preparando para dormir quando os policiais chegaram. O ponto de ônibus não é ponto de droga. Perguntado o motivo de ser acusado pelos policiais, disse que é porque não indicou onde é a casa do "Peixe". É usuário de drogas. Usa crack. Não consegue ficar sem usar a droga. Não tinha dinheiro. Não tinha faca. Era acompanhado pelo CAPS, onde fazia tratamento para dependência química.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

O réu indicou conflito com um dos policiais responsáveis pela sua prisão, fato que diminui a confiabilidade do depoimento dos policiais.

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de

prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Na remota hipótese de condenação, considerando a confissão do acusado, passo a me manifestar acerca da dosimetria da pena.

a) Pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, há que se reconhecer a confissão, ainda que apenas a informal e mesmo que a pena não sofra alteração.

Além disso, o fato de que o acusado é menor de 21 anos também deve ser reconhecido como atenuante.

c) Da aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD. Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo, sendo certo que, conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

d) Antecedentes infracionais e inexistência de prova de dedicação à atividade criminosa

É certo que o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consideram que os antecedentes infracionais não afastam a possibilidade de incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

Na terceira fase, a i. Magistrada afastou a figura do tráfico privilegiado.

Justificou a negativa em razão da dedicação do acusado à prática de atividades criminosas. Embasou sua conclusão no fato de o acusado já ter sido condenado pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Impõe-se, contudo, o reconhecimento do privilégio. O envolvimento em atos infracionais não é fundamento legítimo para se extrair a conclusão de alinhamento em atividades criminosas. Isto porque, a resposta estatal para as situações que cercam as crianças e os adolescentes funda-se em premissas diversas, anteriores à imputabilidade penal. Assim, por não configurarem crime ou contravenção penal não parece razoável possam ser consideradas como envolvimento em atividades criminosas a ponto de se afastar a incidência do redutor. Aliás, conforme já decidido por esta Colenda Câmara, a existência no prontuário do réu de apenas um apontamento de ato infracional não revela justificativa idônea para indicar seu envolvimento habitual a atividades criminosas. (TJSP, Apelação n. ° 1500892-95.2020.8.26.0594, 16ª Câmara, r. Des. Marcos Zilli, j. 21/09/2021).

É o caso, portanto, de reconhecimento do privilégio, devendo a pena ser diminuída em seu grau máximo.

e) Da incidência da causa de diminuição prevista pelo art. 41 da Lei de Drogas

Caso se tome como verdadeira a versão policial, tem-se que o réu acabou por indicar o local onde se encontrava a droga, permitindo a sua apreensão.

Dispõe o artigo 41 da Lei de Drogas que “o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do

produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”.

Não obstante a Lei nº 11.343/2006 não defina o que é “produto do crime”, ela o diferencia da ideia de “proveito” previsto no art. 60 desse diploma normativo, que seria o benefício econômico advindo o tráfico, por exemplo, o dinheiro.

Guilherme de Souza Nucci estabelece, especificamente no contexto do art. 41 da Lei de Drogas, que “produto do crime” é a droga e não o lucro ou vantagem que a sua inserção no mercado acarretaria: “Menciona a norma do art. 41 o produto do delito e não o proveito. Logo, é a substância entorpecente, que necessita ser recuperada, total ou parcialmente [...]” (NUCCI, 2017, p. 979).

Assim, uma vez compreendido que o produto do crime é a substância entorpecente propriamente dita, uma vez que o acusado tenha voluntariamente colaborado para sua localização, terá ele direito à redução da pena.

Nesse ponto, cabe esclarecer que os requisitos do art. 41 da Lei de Drogas devem ser interpretados de forma alternativa, em conformidade com o instituto da colaboração premiada previsto na Lei de Organização Criminosa, aplicando-se a minorante nos casos de efetiva contribuição para localização das drogas OU de identificação de coautores ou partícipes.

Isso porque a cumulatividade dos requisitos a um só tempo (i) feriria o princípio da proporcionalidade ao não valorar o efetivo auxílio prestado pelo acusado à autoridade policial; (ii) retiraria a efetividade da norma legal quando o tráfico não fosse praticado em concurso de pessoas; (iii) colidiria com os objetivos do legislador ao prever a colaboração como meio de produção de provas e (iv) representaria indevida confusão entre os institutos da delação premiada e da colaboração premiada, na medida em que aquele é espécie deste último, que tem incidência mesmo que não se delate qualquer comparsa.

Assim, de forma a conferir racionalidade e eficácia à norma contida no art. 41 da Lei de Drogas, mostra-se necessário adotar uma interpretação sistêmica e teleológica do instituto da colaboração premiada, analisando-o à luz da normativa prevista na Lei de Organizações Criminosas.

O artigo 4º da Lei nº 12.850/13 prevê cinco formas alternativas – segundo o caput do artigo – por meio das quais o(a) acusado(a) poderá colaborar com a investigação e com o processo: (i) identificar os demais coautores e partícipes da organização criminosa e as infrações penais por eles praticadas; (ii) revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa; (iii) prevenir as infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; (iv) recuperar total ou parcialmente o produto ou o proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e (v) localizar o paradeiro de eventual vítima com sua integridade física.

De acordo com o regime jurídico da Lei de Organizações Criminosas, é suficiente, portanto, que apenas uma dessas situações esteja preenchida para que o(a) acusado(a) faça jus à redução da pena.

Para Claudia Lima Marques, entre a Lei de Drogas e a Lei de Organizações Criminosas há um diálogo de influências recíprocas sistemáticas, existente quando os conceitos estruturais de uma lei são influenciados por outra. “É a influência do sistema especial no geral e do geral no especial, um diálogo de duplé sens (diálogo de coordenação e adaptação sistemática)” (MARQUES, 2007, p. 91).

Destarte, adotando-se uma interpretação sistêmica e teleológica do art. 41 da Lei de Drogas, em consonância com a normativa geral posteriormente trazida pela Lei de Organizações Criminosas, faz-se imprescindível admitir a alternatividade dos requisitos da colaboração premiada, aplicando-se o redutor de pena quando o auxílio do(a) acusado(a) resultar na recuperação total ou parcial da droga, independentemente da delação de outros agentes.

No presente caso, verifica-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em sede policial quanto em juízo, que a colaboração do réu foi imprescindível para a localização da maior parte dos entorpecentes, sendo certo que o referido auxílio foi por ele prestado de forma voluntária. Portanto, ele fazendo jus à causa de diminuição de pena expressa no referido artigo.

De mais a mais, com relação ao quantum da minorante, é necessário que seja aplicado

no patamar máximo, de 2/3 (dois terços) porque se não fosse a colaboração voluntária do réu possivelmente os entorpecentes não teriam sido apreendidos.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto. Caso o privilégio seja reconhecido, requer seja fixado regime aberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Finalmente, reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

No mais, no atual cenário, qualquer decisão que determina o recolhimento de alguém ao cárcere ou a manutenção de uma prisão anteriormente decretada deve ser ponderada à luz da crise sanitária causada pelo COVID-19. Considerando a situação emergencial de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), somada ao fato de que estabelecimentos em que há aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis à disseminação de doenças virais, e visando a reduzir ao máximo os riscos advindos de uma possível contaminação por coronavírus, principalmente dos sujeitos ainda protegidos pela presunção de inocência e acusados de crime não considerados graves, mostra-se imperiosa a concessão do direito de apelar em liberdade, caso o acusado seja condenado.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

JONATHAS FELIPE DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de novembro de 2021, por volta de 03h35, na via pública, na avenida Professor Alberto Volet Sachs, altura do numeral 1.403, bairro Nova América, nesta cidade e comarca, trazia consigo duas porções de cocaína e mantinha em depósito 58 porções de cocaína e 28 porções de maconha destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local, quando avistaram o réu em local conhecido como "ponto de venda de drogas", o qual estava parado na via pública. Feita abordagem de praxe, na sua posse foram encontradas 02 porções de cocaína e a quantia de R\$ 29,00 (vinte e nove reais) em notas trocadas. Instado, o réu indicou onde mantinha o restante do entorpecente, ou seja, no terreno baldio, próximo ao local, dentro de uma sacola plástica foram localizadas 58 porções cocaína e 28 porções de "maconha", as quais o réu admitiu que se destinavam à mercancia ilícita.

Diante das circunstâncias apuradas, apreensão de porções individualizadas para venda e confissão informal do réu, infere-se que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida, sem oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 141/142), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 143/144).

Notificado (fls. 152), o réu apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 156/159).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência virtual (fls. 179/182). O réu foi citado (fls. 201).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 12/14, na fotografia de fls. 30/33, no laudo de constatação de fls. 16/20, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 176/178, segundo o qual foi detectada a presença das substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), nos materiais periciados.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu calado (fls. 06).

Em Juízo, o réu afirmou que estava morando na rua. naquele dia, sofreu abordagem e o policial perguntou se conhecia traficantes. O policial disse que se não passasse a casa de um "Peixe", quando fizesse 18 anos, seria preso. Iria dormir no ponto de ônibus, mas foi abordado. O policial queria saber da casa do "Peixe", mas disse que não sabia. Depois, o policial pegou uma sacola e chegou outra viatura. Foi preso pela droga da sacola, que não era sua. Foi outra viatura que o abordou, com o policial que disse que queria saber do "Peixe". A droga estava dentro da viatura, foi retirada e, depois, a policial feminina foi até a mata e saiu com a droga, dizendo que lhe pertencia. A droga não lhe pertencia. Não dormia sempre no mesmo lugar. O local não é ponto de venda de drogas. está sendo acusado, porque não sabe onde era a casa do "Peixe", para contar aos policiais. Não tinha nenhum dinheiro consigo. Também não tinha faca consigo. Faz uso de crack e não consegue ficar sem consumi-lo. Era acompanhado pelo Caps, em tratamento de dependência, antes de ser preso. Nunca trabalhou registrado. Não se recorda se teve passagem por tráfico de drogas.

A autoria, contudo, restou comprovada nos autos, conforme se verifica das provas. Vejamos.

A policial militar Mayara de Souza Silva relatou que estavam em patrulhamento, em local conhecido como ponto de venda de drogas. levantou suspeita também, o fato de ele estar naquela hora, de madrugada, no ponto de ônibus. Não há circulação de ônibus, nesse horário. O réu estava de pé e sozinho. O réu foi abordado e, com ele, encontraram 02 pinos de cocaína, dinheiro no bolso e uma faca. Indagado, o réu indicou o outro lado da via, numa área de mata, próximo de uma árvore, não escondida, onde havia uma sacola contendo cocaína e maconha. Não conhecia o réu. O também policial militar Maycon Morato de Lima asseverou que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu num ponto de ônibus, em local conhecido por ser tráfico de drogas. Com ele, havia 02 pinos de cocaína, R\$ 29,00 e uma faca. Indagado, o réu confessou a prática delitiva e disse que havia mais drogas numa mata, do outro lado da via, onde encontraram uma sacola com o restante da droga, salvo engano maconha e cocaína. O réu foi avistado sozinho e sentado. Salvo engano, não havia circulação de ônibus, naquele horário. Não conhecia o réu. pelo que se recorda, não havia cobertores ou papelão perto do réu, que não aparentava ser morador de rua. não apreendeu o réu, quando ele era adolescente. Por questão de segurança, pediram apoio a outra viatura. Não sabe se os policiais da outra viatura conheciam o réu.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, que se manifestou apenas em Juízo, alegou que a droga não lhe pertencia, que foi retirada pelos policiais de dentro da viatura, e que nada de droga tinha em seu poder.

Os policiais militares narraram que avistaram o réu sozinho, parado em ponto de ônibus, em local conhecido como ponto de venda de drogas e, por isso, suspeitaram de sua conduta. Além do local, naquele horário, já não havia mais circulação de ônibus na cidade. Em revista pessoal, com o réu, eles encontraram 02 microtubos de cocaína, uma faca e R\$ 29,00 em dinheiro trocado. Indagado, o réu confessou a prática delitiva e indicou que manteria outras porções de entorpecentes em uma mata, localizado do outro lado da via, dentro uma sacola plástica. No local indicado, os policiais encontraram a sacola, dentro da qual havia outros 58 microtubos de cocaína, embalados de forma idêntica àqueles encontrados em poder do réu, e 28 porções de maconha.

Nesse sentido, temos duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, que nega qualquer envolvimento com a droga apreendida, e a dos policiais, segundo o qual o próprio réu indicou as drogas localizadas na mata e com ele havia 02 pinos de cocaína.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Considerando que o réu estava parado e sozinho em ponto de venda de drogas, bem como que a maior parte da droga foi encontrada escondida na mata, entendo que seria dificultoso aos policiais a localização do entorpecente.

De outro lado, a embalagem da droga apreendida com o réu era exatamente idêntica àquelas que foram encontradas na mata.

Por fim, traficante não deixa sua droga escondida, se não tiver acesso e visualização dela, o que importa dizer que se não havia outra pessoa parada no local, a responsabilidade por toda a droga era mesmo do réu.

Assim, devemos dar crédito à versão policial.

Importante mencionar que a suposta divergência entre o réu e um policial militar não foi comprovada, até porque o réu nem mesmo pode indicar quem seria o suposto policial que queria que ele lhe informasse a residência de um traficante, sobe pena de uma prisão indevida.

Ainda que assim não fosse, a palavra das autoridades militares, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal. Ressalto que o depoimento dos policiais foi firme, unísono e inquestionável.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018 - grifei).

Ressalto que os policiais militares não conheciam o réu e se quisessem prejudicá-lo poderiam ter feito com menor quantidade de drogas.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

“O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12” (TJRS – Ver. 695102699 – Rel. José Eugênio Tedesco – RJTJRS 175/54).

“Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei” (TJRS – Ver. – Rel. Rubens Rebelo Magalhães – RJTJRS 74/11).

No caso dos autos, o réu negou a posse ou guarda de qualquer entorpecente. A prova confirma, contudo, a destinação e consumo de terceiras pessoas.

Inicialmente, o réu foi avistado parado e sozinho, em ponto de venda de drogas.

Embora com ele houvesse pouca quantidade de cocaína (02 microtubos de cocaína) o fato é que ele tinha escondido o restante do entorpecente, situação comum e ocorrer entre os traficantes que permanecem nos pontos de venda com pouca ou nenhuma quantidade de droga e deixam o restante nas proximidades, em local que possa visualizar, para monitorar, e buscar rapidamente, para a venda.

De outra banda, a quantidade e diversidade da droga (60 porções de cocaína e 28 porções de maconha) indicam que a droga não tinha como destinação o consumo do

próprio réu, na medida que não é usual usuários manterem tanta droga na rua.

Com o réu, havia dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada.

Por fim, ao policial militar Maycon, o réu confessou a prática delitiva.

Assim, o local da abordagem, a quantidade e diversidade da droga, a forma de embalagem do entorpecente, a existência de dinheiro, a confissão informal do réu, tudo revela que a droga tinha como destino o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que mesmo que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada